

1501043-75.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... a sentença de um homem condenado por tráfico, aplicando a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). De acordo com a decisão de primeira instância, o reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado com fundamento em atos infracionais praticados pelo réu na adolescência, que revelariam dedicação à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501043-75.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188870/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 2188870 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ADRIANO ALMEIDA JUNIOR

Réu Preso

Contr. nº 2022/000816

Aos 03 de outubro de 2022, às 16:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel, foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu JOSE ADRIANO ALMEIDA JÚNIOR (preso).

Presente o(a) defensor(a) constituído, Dr(a). Rogério Evangelista Leite.

Presentes as testemunhas de acusação: PMs Luis Augusto e Anderson Luis.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, através de exibição à câmera de documento original com foto, foram colhidos o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Luiz Augusto e PM Anderson) e, em seguida, o interrogatório do réu,

todos captados e gravados em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). 1. JOSE ADRIANO ALMEIDA JUNIOR foi(ram) denunciado(s) e está(ão) sendo processado(s) como incurso(s) no art. 33, caput, da LD. De acordo com a denúncia, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 3 horas e 54 minutos, na rua Promissão, bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca, JOSE ADRIANO trazia consigo e transportava, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 259 microtubos contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 207,7g; e 13 microtubos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 21g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 60, 87, 92/96 e 186. 3. A materialidade delitiva foi pelas seguintes peças seguintes: auto de prisão em flagrante de fls. 1 e ss; laudo de fls. 84/86; fotografia de fls. 15; e BOPM de fls. 154/158. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os PMs Luiz e Anderson contaram, em audiência judicial, que avistaram o réu no interior de seu veículo Renault em local conhecido por ser ponto de tráfico. Havia dois indivíduos ao lado do veículo, trocando alguma coisa. Diante da guarnição, o denunciado e os dois suspeitos empreenderam fuga. O réu foi alcançado e submetido à busca, logrando-se encontrar as drogas e dinheiro mencionados na denúncia. Havia entorpecentes no bolso do acusado e no assoalho do veículo. Interrogado, o réu disse que as drogas lhe pertenciam e se destinavam ao próprio uso. Não há como acolher essa alegação. A quantidade de droga deixa evidente que a droga se destinava ao tráfico, impondo-se a procedência. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores. A quantidade de droga autoriza a incidência de aumento na pena-base e os antecedentes de atos infracionais repelem o privilégio. O regime fechado se mostra adequado, diante das circunstâncias destacadas. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: Excelentíssima juíza. Trata-se de apuração de crime de tráfico de drogas, que, segundo se recolhe da peça acusatória de fls. 57/59, no dia 13 de julho de 2022, na madrugada, no bairro Itapuã, na cidade de Piracicaba/SP, José Adriano Almeida Júnior, trazia consigo, para o fim de praticar tráfico de drogas para venda de consumo de terceiros, 259 porções de cocaína, na forma de crack, com peso bruto aproximado de 207,7 gramas, e, 13 porções contendo peso bruto de 21 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de importância em espécie de R\$ 275,00 reais. Diante da quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias dos fatos, foi o réu preso em flagrante. Por tais razões, fora o acusado denunciado as fls. 57/59 e encontra-se processado por este ínclito juízo em virtude da ocorrência dos fatos que segundo entendimento do Ministério Público, subsumem-se à norma penal incriminadora inserta no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na mesma denúncia houve pedido expresso do Ministério Público quanto ao perdimento do veículo RENAULT placa AKV1B94, pertencente a terceiro de boa-fé. Recebida a denúncia, encontram-se processado por este ínclito juízo. Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia as fls. 92/96. Em ato contínuo, foi apresentado incidente de restituição de coisa apreendida por terceiro de boa-fé, cujo provas encontram-se aos autos incidental a este processo criminal. Em audiência designada, ouviu-se as testemunhas de acusação que em nada contribuíram para os fatos, e, após, interrogado o réu sobre os fatos, tendo este confessado de forma espontânea a prática do ilícito, assim como já confessado em sebe policial. Eis os breves relatos dos autos. No mérito, Excelência, é de solar clareza, no cenário jurídico atual, que o crime de tráfico de drogas, necessário se faz apontar que a conceituação ou caracterização do crime de tráfico de drogas se fazem necessárias a existência de ato mínimo de comércio, que demonstre de forma inequívoca a prática criminosa da pessoa para o fim de comercialização com obtenção de lucro. De modo que, além da apreensão das drogas é

imprescindível evidências que esta pessoa atue como traficante, o que não há no caso dos autos, como a apreensão de celulares, somas elevadas de dinheiro, cadernos de registro, balança de precisão ou qualquer outro elemento que registre a venda para outros usuários ou distribuidores, apetrechos para fracionamento, distribuição ou qualquer outro elemento coletado em provas de investigação prévia que são comuns àqueles que são praticantes da ação delitiva de tráfico de drogas e entorpecentes. No presente caso não ocorreu as circunstâncias aqui, caracterizando flagrante ausência de provas de autoria de traficância, sendo que o valor apreendido é produto de comercialização/venda de ovos de galinha. O testemunho dos agentes policial em audiência de Instrução e julgamento, ora testemunhas da acusação, nada contribuíram para clareza dos fatos que pudesse, no mínimo, trazer a verdade sobre os fatos e a autoria sobre o réu, inclusive a testemunha Luiz Augusto não soube informar a quantidade de drogas apreendidas em posse do réu, e que no bolso esquerdo havia somente cocaína e não crack como consignou na denúncia, o que se observa em testemunhos previamente ajustados entre os policiais militares. As folhas de antecedentes criminais do réu foram juntadas as fls. 62/63, que demonstram ser o réu primário e não é traficante, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades de tráfico de drogas. Portanto, posto isto, inescusável a ABSOLVIÇÃO, requerendo a defesa pela improcedência da denúncia com a ABSOLVENDO O RÉU, ante a insuficiência de provas para condenação do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso Vossa Excelência entenda pela condenação do réu, o que diz apenas a título de argumentação e defesa técnica, requer a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação a réu José Adriano Almeida Júnior, nos termos do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06, com a diminuição da pena ali consignada em seu patamar máximo, pois, além da primariedade, o réu não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas. Por outro lado, em que pesem as ocorrências de atos infracionais em desfavor do réu, a prática de ato infracional não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena, como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. Assim, segundo entendimento da jurisprudência da suprema corte, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o juízo da 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, São Paulo altere a sentença de um homem condenado por tráfico, aplicando a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). De acordo com a decisão de primeira instância, o reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado com fundamento em atos infracionais praticados pelo réu na adolescência, que revelariam dedicação à prática de delitos. O relator, ministro Nunes Marques, afirmou que o entendimento do juízo de primeiro grau, confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, destoa da jurisprudência consolidada do STF, caracterizando-se como manifestamente ilegal. "Isso porque a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais, cometidos pelo acusado, não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado", ao conceder o Habeas Corpus nº RHC 208.023 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é o suficiente para que seja reconhecida a figura privilegiada do tráfico em favor do réu José Adriano de Almeida Júnior. Passando a dosimetria da pena, requer a defesa seja aplicada as seguintes penas ao réu: Na primeira fase da aplicação da pena, tendo em vista ser o réu José Adriano Almeida Júnior, réu PRIMÁRIO, seja aplicada a pena base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas, porém, há causa de reconhecimento e a aplicação de duas atenuantes, sendo elas, a primeira, da pena de confissão espontânea, por quanto o réu, confessou, espontaneamente em sede policial e em sede judicial, o que merece a redução da pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, e a segunda, a atenuante da pena por ser o réu menor de 21 anos na data dos fatos, o que merece redução da pena, nos termos do artigo 65, inciso I do Código Penal. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de aumento da pena, porém, há a causa de diminuição da pena a ser considerada, tendo em vista a natureza

privilegiada do crime, ou seja, deve-se reconhecer o tráfico privilegiado, em relação ao réu, com a diminuição da pena em grau máximo, nos termos do § 4º, da Lei 11.343/06, lei de drogas, diante da citada jurisprudência da suprema corte. O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o regime aberto, pois com o reconhecimento do tráfico privilegiado e atenuação das penas pela confissão e menor de 21 anos data dos fatos, e, sendo o réu primário não reincidente, a pena será inferior a 2 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal. Posto isto, requer seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, eis que o réu não é reincidente, e o crime não foi cometido com violência e grave ameaças, bem como a conduta social, os antecedentes e a culpabilidade do réu indicam a presente substituição de pena. Com a aplicação da pena nos moldes dito pela defesa, requer seja posto o réu em liberdade, expedindo o competente alvará de soltura em seu favor. Assim, reitera-se a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, tendo em vista o pedido de restituição de coisa apreendida feito por incidente processual, requer, neste momento, considerando terceira pessoa de boa-fé ter contratado o mesmo advogado deste auto principal, digne-se Vossa Excelência a restituir o automóvel RENAULT placa AKV1B94, para a pessoa de Pâmela Carol de Meneses, proprietária, terceira pessoa de boa-fé e empregadora de trabalho do réu, cujo desconhecimento tinha de que o réu portaria ou usaria drogas ilícitas, conforme documento do veículo juntado aos autos de restituição de coisa apreendida. É o que se requer! A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

JOSÉ ADRIANO ALMEIDA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 3 horas e 54 minutos, na Rua Promissão, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 259 microtubos contendo cocaína, na forma de pedras de crack, com peso bruto aproximado de 207,7g; e 13 microtubos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 21g (cf. laudo de constatação de fls. 16/18), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que José foi ao local com o veículo RENAULT de placas AKV1B94 para realizar tráfico e que policiais militares, em patrulhamento de rotina, passaram pelo lugar, vendo-o ali parado com o referido veículo, em local conhecido como ponto de drogas.

Narra, outrossim, que ao notar a presença da guarnição, o réu empreendeu fuga com o citado automóvel, sendo posteriormente alcançado na comunidade Portelinha.

Narra, ademais, que, feita a busca pessoal, os PMS apreenderam em poder de José 54 eppendorfs contendo crack; além de R\$ 275,00 proveniente do tráfico. No interior do veículo, os servidores localizaram 205 eppendorfs contendo pedras de crack e 13 porções de cocaína.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 86). Defesa preliminar apresentada às fls. 92/96. Após, a denúncia foi recebida (fls. 123/124) e o réu foi citado (fls. 166).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 07/09;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e fotografia de fls.15;

3) laudo de constatação preliminar de fls. 16/18 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 84/86, os quais atestaram resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05/06), o réu disse que é usuário de entorpecentes e que as drogas encontradas em seu veículo são de sua propriedade, destinadas a seu uso. Alegou desconhecer a quantidade de porções que trazia consigo. Asseverou que, quando menor de idade, foi apreendido por atos infracionais equiparados a tentativa de homicídio e tráfico de entorpecentes.

Interrogado em juízo (gravação), o réu repetiu a versão anterior, admitindo a posse das drogas e alegando que eram destinadas a seu uso. Disse trabalhava fazendo vendas de ovos para sua tia e, com essa atividade ganhava cerca de um salário mínimo por mês. Afirmou que cada porção de crack custa R\$ 5,00 e de cocaína R\$ 10,00.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Luiz Augusto da Silva disse que, na data da ocorrência, estavam em patrulhamento pela Rua Promissão quando viram um veículo Renault Kangoo parado no local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico. Viram que, ao lado dele, havia dois rapazes que entregaram algo ao condutor do automóvel. Assim, que notaram a aproximação da viatura, os rapazes correram a pé em direção à comunidade Pantanal, que só permite acesso a pé, ao passo que o motorista empreendeu fuga com o automóvel em direção à favela Portelinha. Saíram ao seu encalço, até que ele entrou numa rua sem saída e não conseguiu mais fugir. Ao ser abordado, ele se identificou como sendo o réu, José Adriano Almeida Júnior.

Asseverou que, em sua posse, encontraram duas porções contendo 27 “flaconetes” de crack e, em sua carteira, R\$ 275,00 em notas trocadas. Disse que, no interior do veículo, no assoalho do passageiro, encontraram 205 porções de crack, e 13 porções de cocaína. Por fim, declarou que não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação) pelo policial militar Anderson Luiz, o qual acrescentou que, salvo engano, o carro era de propriedade de um parente do réu e que este alegou que era usado para vendas de ovos. No entanto, não se recordava de ter encontrado ovos em seu interior.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova

coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo as drogas descritas na denúncia, para fins de mercancia.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que, em patrulhamento de rotina pelo local, depararam-se com o acusado dentro do veículo mantendo contato com dois transeuntes, de quem recebeu algo (certamente era dinheiro, porque, posteriormente, com ele foram encontradas diversas porções de entorpecentes e dinheiro trocado com ele, o que indicava que quem realizava as vendas era ele e não os transeuntes) e, ao perceberem a presença da viatura, todos empreenderam fuga (os transeuntes a pé e o réu com o veículo).

Ao ser abordado, os policiais encontraram as 259 porções de crack e 13 invólucros de cocaína (fotografia de fls. 15) na posse dele e no interior do automóvel, além de dinheiro trocado.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes que o réu trazia consigo confirmam o destino mercantil, pois absolutamente incompatíveis com a situação do mero usuário.

Some-se a isso o fato de os entorpecentes estarem embalados em porções individuais, da forma como comumente são comercializados, bem assim o fato de ter sido encontrada quantia em dinheiro (R\$275,00), em notas trocadas, o que, aliado à falta

de comprovação idônea por parte da Defesa, da origem lícita, faz presumir decorrer do comércio ilegal e confirma o destino mercantil dos entorpecentes, ensejando, inclusive, seu perdimento para a União.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolução – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 62/63).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, aplico-lhe as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade, mas deixo de diminuir as penas, pois circunstâncias atenuantes não autorizam a redução aquém do mínimo legal.

Não há agravantes.

Inexistem causas de aumento.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui condenações na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas (fls. 108/114 – com medida de internação) e de homicídio simples (fls. 115/122 – medida de internação), o que, aliado ao fato de não ter comprovado exercer atividade lícita e trazer consigo expressiva quantidade e diversidade de drogas, demonstra que vem se dedicando às atividades criminosas e, inclusive, fazendo do tráfico seu meio de vida.

Tal fato demonstra que o réu tem total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou traficando.

Trata-se, portanto, de traficante que vem reiterando nas atividades criminosas, não se podendo equipará-lo aos pequenos e eventuais traficantes.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se dedicado às atividades criminosas desde a adolescência, não comprovando atividade lícita, além de trazer consigo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, há diversos julgados, inclusive do C. STF e C. STJ:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Ação penal com trânsito em julgado para afastar a incidência da causa especial de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Constrangimento ilegal não caracterizado. Agravo ao qual se nega provimento. 1. segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena pelo delito de tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. Para negar a redutora prevista na Lei de Drogas, o Superior Tribunal de Justiça apontou, no acórdão condenatório, que o paciente possui condenações por atos infracionais anteriores. Embora esses registros criminais não possam ser utilizados como maus antecedentes, tampouco como reincidência, nada impede que o seja como prova da dedicação do acusado à atividade criminosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - HC 211261 AgR. Primeira Turma. Relator(a): DIAS TOFFOLI - J. 11/04/2022.) – g.n.

“EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (STF - HC 192147. Primeira Turma. AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI – j. 24/02/2021) – g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, os fatos em análise datam de 19/3/2021, em que o acusado foi surpreendido na posse de 149,8g (cento e quarenta e nove gramas e oito decigramas) de crack e 481,75g (quatrocentos e oitenta e um gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha e, consoante a folha de antecedentes criminais acostada aos autos, em 26/3/2021, foi cumprida a medida socioeducativa a ele imposta pela prática de ato infracional análogo ao delito do

art. 157, § 2º, II, do CP, além da prática de diversos outros atos infracionais, incluindo a apuração de ato análogo ao crime em apreço, o que justifica o afastamento do pretendido redutor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no HC n. 724.241/MG. Sexta Turma. relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro - J. 9/8/2022) - g.n.

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso dos autos, em que pese a Corte de origem invocar a quantidade e natureza de drogas para majorar a basilar e afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, de per si, configuraria indevido bis in idem, verifica-se que ainda invocou fundamento para afastar a referida causa especial de diminuição de pena que está em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência admite que sejam invocadas anotações infracionais pretéritas para aferir a dedicação do acusado a atividades criminosas, notadamente diante da grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, tratando-se de "227,78 gramas de maconha e 13,2 gramas de cocaína" (fl. 272). III - Com efeito, tendo a Corte assentado que "o acusado possui anotação pela prática de ato infracional análogo à prática do tráfico de drogas (proc. 0006763-36.2019.8.26.0136 fls. 63)" (fl. 272), evidenciando ser registro recente que, somado às demais circunstâncias do caso concreto, torna inviável entender de forma contrária às instâncias ordinárias quanto à dedicação do agravante a atividades criminosas, pois demandaria aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. IV - Ressalte-se, por oportuna, que ao contrário do esposado no parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão da ordem para reconhecer o privilégio, a dedicação a atividades criminosas não decorreu unicamente da quantidade e diversidade de drogas, ou com base em ações penais em curso, mas sim em face da existência de registro de antecedente infracional específico que, somado às demais circunstâncias fáticas, evidenciam a dedicação do agravante ao comércio espúrio. V - Por fim, tem-se que o regime mais gravoso foi devidamente justificado na grande quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida que, na forma do art. 42 da Lei de Drogas e 33, § 2º, b e § 3º, do CP, legitima o recrudesimento do regime inicial, ainda que o paciente seja tecnicamente primário e tenha sido condenado a pena inferior a oito anos de reclusão. Precedentes. VI - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC n. 733.091/SP, Quinta Turma. relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) - j. 21/6/2022) - g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,913KG (UM QUILO E NOVECENTOS E TREZE GRAMAS) DE MACONHA E 8G (OITO GRAMAS) DE COCAÍNA. PETRECHOS E ANOTAÇÕES RELATIVAS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABITUALIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que "atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal" (HC n. 650.819/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021). 2. Tendo o Tribunal de origem indicado a prática de ato infracional

análogo ao crime de roubo, no caso concreto, essa indicação, associada à apreensão de elevada quantidade de drogas - aproximadamente 1,913kg (um quilo novecentos e treze gramas) de maconha e 8g (oito gramas) de cocaína -, petrechos e anotações relativas ao tráfico de entorpecentes, em conjunto, denota habitualidade delitiva apta a afastar a aplicação da causa redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp n. 1.948.298/T0, Sexta Turma. relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro - j. 5/4/2022) - g.n.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes que os pacientes se dedicam ao comércio espúrio, com fulcro nos elementos constantes dos autos, sobretudo no fato de registrarem atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a", do CP. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC n. 711.617/SP. Quinta Turma. relator Ministro Ribeiro Dantas - j. 8/2/2022) - g.n.

Incabível, assim, o privilégio.

Quanto ao regime de pena, deixo de fixar o fechado para eleger o semiaberto, eis que o réu é primário, de bons antecedentes e a quantidade de droga, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância e de se tratar de traficante de grande envergadura.

No entanto, a pena é superior a quatro anos e inferior a oito e, por outro lado, conforme exposto, o réu vinha, desde a adolescência, envolvendo-se em atividades criminosas, o que justifica a eleição do regime intermediário.

Ademais, o crime de tráfico de drogas tem graves consequências, fomentando a prática de vários outros delitos, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Necessária, assim, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato e, considerando que já vem traficando há algum tempo, desde que era menor de idade, muito provavelmente continuaria a realizar o nefasto comércio. Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e vinte dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu JOSÉ ADRIANO ALMEIDA JÚNIOR a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 275,00) é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Em relação ao veículo apreendido, não restou demonstrado que era usado para o tráfico, de modo que deixo de decretar seu perdimento, ressaltando que a análise do

pedido de liberação deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público.

No mais, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida. De fato, conforme acima exposto, o réu possui envolvimento pregresso com a prática de atos infracionais análogos a tráfico de drogas e homicídio e, ao atingir a maioridade, permaneceu na vida da criminalidade, exercendo o nefasto comércio ilícito de drogas, o que indica maior periculosidade e real possibilidade de reiteração criminosa.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhida, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Vistos,

Recebo o recurso interposto pela Defesa.

Desde já sai a defesa intimada do prazo para apresentação das razões de apelação, CUJO TERMO INICIAL SE DARÁ COM A DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA NOS AUTOS, independentemente de nova intimação, uma vez que se trata de processo digital e o recurso foi recebido neste momento.

Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Sem prejuízo, aguarde-se o prazo legal para a acusação acerca de eventual recurso. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, ASSF, assistente judiciário, digitei.